

1508961-31.2020.8.26.0590

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Alexandre Torres de Aguiar

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/03/2022

... absolvição do réu quanto ao crime de roubo, por falta de provas quanto à sua participação neste crime. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, em sua forma tentada. Quanto à dosimetria da pena, requereu a fixação da pena-base em seu mínimo legal, bem como o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

1ª Vara Criminal

Rua Jacob Emmerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1508961-31.2020.8.26.0590 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508961-31.2020.8.26.0590

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME CARDOSO PEREIRA DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Torres de Aguiar

Vistos.

GUILHERME CARDOSO PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e 2º-A, inciso I, do Código Penal, bem como no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, ambos c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal porque, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas na denúncia, em ocasião de calamidade pública, agindo previamente acordado e com unidade de desígnios com um adolescente e com outros dois indivíduos ainda não identificados, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu para si o aparelho de telefone celular, a carteira contendo documentos, o veículo de marca Honda, modelo Fit, com placas FWG2528/São Vicente, onde havia equipamentos de trabalho da vítima, como maleta com medicamentos

veterinários, uma máquina de oxigênio e um aparelho de anestesia veterinário, bens pertencentes à vítima D.P.S.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, em ocasião da calamidade pública, o réu facilitou a corrupção de pessoa menor de dezoito anos de idade, com ela praticando infração penal.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação.

Em audiência, foram ouvidas a vítima e uma das testemunhas arroladas na denúncia, sendo homologada a desistência quanto à oitiva de uma das testemunhas policiais militares. Restou prejudicada a oitiva, na qualidade de informante do Juízo, da testemunha apresentada pela Defesa durante a audiência. Ao final foi o réu interrogado.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação do réu pela prática do crime de roubo descrito na denúncia, diante da prova produzida. Quanto à dosimetria da pena, pediu a fixação da pena-base acima de seu mínimo legal, bem como o reconhecimento das circunstâncias agravantes e atenuantes referentes à calamidade pública e à menoridade relativa. Requereu o reconhecimento das causas de aumento de pena quanto ao emprego de arma e ao concurso de pessoas e, ao final, pediu a fixação do regime inicial fechado. Quanto ao crime de corrupção de menores, pediu a absolvição do réu, por falta de provas.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu quanto ao crime de roubo, por falta de provas quanto à sua participação neste crime. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, em sua forma tentada. Quanto à dosimetria da pena, requereu a fixação da pena-base em seu mínimo legal, bem como o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, o reconhecimento da tentativa e formulou, outrossim, pedidos relativos à fixação do regime prisional.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição, apreensão e entrega, pelo laudo pericial, bem como pela prova oral colhida em Juízo e demais elementos amealhados aos autos.

A autoria também é certa.

Interrogado em Juízo, o acusado negou a prática do crime descrito na denúncia. Disse que foi com seus amigos Marcos Antonio e Lucas a um local, no mato, onde há uma pista que utilizam para manobras em motocicletas e, ao final dessa pista, havia um veículo de marca Honda. Alegou que, ao aproximarem-se desse veículo, dois a três policiais saíram do mato e os abordaram, mandaram que deitassem e os fotografaram. Contou que foram acusados da prática de roubo do carro e foram levados à delegacia. Disse que ninguém estava portando ferramenta e alegou que, ao serem abordados, não haviam tocado no veículo, pois ainda estavam sobre as motocicletas e com capacetes. Disse que nenhum indivíduo menor de idade estava em sua companhia e negou conhecer Jhonatan. Não soube por que motivo foi reconhecido pela vítima como autor do roubo e alegou já ter sido abordado por outros policiais antes dos fatos. Disse que foi conduzido à delegacia com Marcos Antonio e Lucas e estava ao lado deles para reconhecimento quando foi indicado pela vítima. Contou que, na noite anterior aos fatos, estava com Marcos e Lucas na adega instalada no quintal de sua casa, onde ficaram conversando e, por volta de meia-noite a adega fechou, seus amigos foram embora e entrou em sua casa.

Entretanto, a negativa do réu e a versão por ele apresentada, além de não serem críveis, estão isoladas no conjunto probatório amealhado.

A vítima, quando ouvida sob o crivo do contraditório, confirmou ter sido roubada e descreveu como se deu a ação criminoso e a conduta do acusado. Declarou que, perto de meia-noite na data dos fatos, passava de carro por uma rua quando, subitamente, quatro indivíduos saíram de trás de uma árvore e um deles, que portava arma, a abordou, enquanto os demais vasculharam seu veículo. Disse que os meliantes subtraíram seu veículo com seus materiais de trabalho como médico veterinário, tais como aparelho de oxigênio, monitor de parâmetros, medicações e estetoscópio, além de subtraírem sua carteira contendo entre R\$250,00 e R\$300,00 em dinheiro e cartões de crédito, bem como seu aparelho celular. Relatou que o crime ocorreu em local próximo à casa de seus pais, para onde rumou, e de onde acionou a polícia, sendo-lhe solicitado que fosse à delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Declarou que, no dia seguinte aos fatos, por volta de 13 horas, estava na delegacia, quando foi informado sobre a recuperação de seu veículo e da maioria dos seus materiais de trabalho. Soube que o automóvel e seus objetos de trabalho foram encontrados em locais diversos, pois estes últimos estavam em uma creche na área continental da cidade. Consignou que, naquela mesma data em que estava na delegacia, realizou o reconhecimento pessoal de um dos participantes no crime. Asseverou que o indivíduo que reconheceu, sem dúvidas, tratava-se do acusado, que estava portando arma no momento do roubo. Soube que o réu foi detido quando estava em seu veículo. Consignou que o reconhecimento foi realizado em uma sala, estando o réu ao lado de outros três ou quatro indivíduos. Declarou que o acusado não estava usando máscara facial durante a execução do crime, mas usava um casaco acinzentado com capuz, e descreveu-o como um indivíduo magro, com cor de pele semelhante à sua, e que trajava calça e casaco escuro. Narrou que o réu, além de ameaçá-lo com a arma de fogo, também o agrediu com uma coronhada, que lhe ocasionou um pequeno machucado, e consignou que, após ter sido deitado no chão e revistado pelo acusado, este novamente o agrediu com um golpe em suas costas, embora não tenha reagido ao crime nem tenha feito nada contra aquele. Reconheceu o réu em Juízo, sem dúvidas, como sendo um dos autores do crime. Disse não recordar de tatuagem no pescoço do acusado, esclarecendo que ele estava usando um capuz que cobria parte de sua cabeça e seu pescoço quando da prática do delito.

A testemunha policial militar Carlos Wilker Souza Jorge, ouvida em Juízo, relatou que realizava patrulhamento pelo bairro Samaritá quando um transeunte informou sobre um veículo abandonado em zona de mata fechada. Declarou que, com apoio de outras equipes, foi ao local indicado, onde viu um automóvel e duas motocicletas. Narrou que, ao aproximar-se, viu um indivíduo ao volante do veículo e, ao lado de fora, havia um segundo indivíduo portando uma chave de roda e um terceiro ao lado deste. Disse que, ao ver a equipe, o indivíduo que estava com a chave de roda a dispensou. Realizada a abordagem e a busca pessoal, com os indivíduos abordados nada foi encontrado. Relatou que, em consulta pelos veículos, nada constava em relação às motocicletas, porém constatou que o automóvel havia sido roubado no dia anterior. Declarou que os indivíduos abordados foram conduzidos à delegacia, onde a vítima reconheceu um deles como um dos autores do roubo. Disse que, no local da abordagem, havia uma pista utilizada para manobras de motocicleta e os indivíduos abordados alegaram que lá estavam para esse fim, mas viram o automóvel e dele aproximaram-se, tendo sido esta a mesma versão fornecida pelo réu. Não conhecia o acusado anteriormente aos fatos. Narrou que não havia menores de idade na companhia do acusado durante sua abordagem. Relatou que, na delegacia, manteve contato com a vítima e soube por ela que quatro indivíduos a pé a haviam abordado no bairro Vila Valença, sendo que um deles portava uma arma de fogo que, inclusive, usou para agredi-la com uma coronhada. Não soube se foi o réu ou algum dos outros meliantes quem agrediu a vítima com a arma. Disse que, além do veículo, foram recuperados materiais de trabalho da vítima, que é médico veterinário. Esclareceu que tais objetos de trabalho não estavam no automóvel recuperado, mas, sim, em uma escola no bairro Samaritá e foram encontrados mais cedo naquela mesma data da abordagem.

Em face de toda a prova carreada aos autos, diante do relato da vítima e da testemunha policial, os quais foram fornecidos com segurança e detalhes, não há dúvidas em se concluir que o réu efetivamente participou do delito de roubo descrito na denúncia.

Os depoimentos da vítima e da testemunha policial são coerentes e harmônicos entre si e se complementam, estando em verdadeira consonância com suas declarações prestadas na fase extrajudicial.

Assim, em relação ao depoimento da vítima em casos como o dos presentes autos, destacam-se os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

"A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera. A preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta inocorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si" (TACRIM-SP - AC - Rel. Almeida Braga - JUTACRIM 100/250)

"A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer a do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos" (TACRIM-SP-AC-Rel. Celso Limongi-JUTACRIM 94/341).

Quanto ao testemunho do agente policial, com enorme grau de confiabilidade, também presta-se a viabilizar a condenação do acusado.

Em relação ao valor probatório do depoimento de testemunha policial destaca-se o seguinte entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

"É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte". (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011).

"Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais -Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF 1a Turma - HC n. 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189).

Ao contrário do alegado pela Defesa, não há qualquer dúvidas quanto ao reconhecimento do acusado pela vítima.

Ressalte-se que a vítima afirmou ter realizado o reconhecimento do réu no dia seguinte aos fatos, quando estava na delegacia e soube ter sido seu veículo e

alguns de seus materiais de trabalho recuperados. Asseverou que o acusado estava em uma sala, ao lado de outros indivíduos, e o indicou, sem dúvidas, como um dos autores do crime, o que também se depreende do auto de reconhecimento de fls. 14.

Consignou a vítima que o acusado era o indivíduo que portava arma durante a execução do crime e que a abordou, agredindo-a com o armamento, enquanto seus comparsas vasculhavam seu veículo. Narrou que o acusado usava um casaco com capuz que cobria seu pescoço e parcialmente sua cabeça, razão pela qual não observou, no momento do crime, se ele possuía tatuagem no pescoço.

Em Juízo, a vítima reconheceu o acusado após fornecer a descrição de suas características físicas, demonstrando ampla certeza de ser ele um dos autores do delito de roubo.

Já a testemunha policial, ouvida sob o crivo do contraditório, narrou ter abordado o acusado e outros dois indivíduos, consignando que um deles sentado ao volante do veículo produto de roubo, enquanto outros dois estavam ao lado de fora do automóvel e um destes portava uma chave de roda nas mãos, que dispensou ao notar a presença da equipe policial.

Note-se que a vítima declarou ter tomado conhecimento de que o réu, que reconheceu com ampla certeza como um dos participantes no roubo, havia sido abordado pelos policiais na posse de seu veículo.

Portanto, não restam dúvidas sobre a autoria do crime.

Outrossim, a violência e a grave ameaça restaram bem caracterizadas.

A vítima relatou de que forma o acusado a abordou, portando arma de fogo, e afirmou que, mesmo sem ter reagido à ação criminosa e nada ter feito contra o réu, ele a agrediu com a coronha da arma e, ainda, colocando-a deitada no chão, novamente a agrediu com um golpe em suas costas.

Dessa forma, não resta qualquer dúvida sobre a conduta do réu que, mediante grave ameaça e violência contra a vítima, participou do delito de roubo.

Por consequência lógica, fica afastada a tese de desclassificação arguida pela Defesa.

O roubo efetivamente se consumou, uma vez que o réu e seus comparsas conseguiram apoderar-se da res, invertendo sua posse. Outrossim, parte da res sequer foi recuperada, o que se infere das declarações da vítima.

Finalmente, depreende-se do conjunto probatório amealhado aos autos, que as causas de aumento de pena relativas ao emprego de arma de fogo e concurso de pessoas restaram comprovadas.

A vítima afirmou que o acusado praticou o crime com outros três indivíduos. Declarou que, enquanto o réu a abordou, ameaçando-a e agredindo-a com a arma de fogo, os demais meliantes vasculharam seu veículo, dividindo as tarefas no momento do crime, de maneira a executá-lo de forma mais eficiente, estando, portanto, bem demonstrada a majorante relativa ao concurso de agentes.

Da mesma forma, a vítima ressaltou a utilização de arma de fogo pelo réu durante a ação criminosa, tendo salientado, ainda, que o armamento foi utilizado pelo acusado para agredi-la.

Finalmente, a ausência de apreensão da arma usada no crime não afasta a majorante. Nesse sentido, destaca-se o entendimento do extinto Tribunal de Alçada Criminal -

TACrimSP:

"ROUBO QUALIFICADO - Ausência de apreensão da arma - Irrelevância. O fato de não ser apreendida a arma usada no crime de roubo não afasta a qualificadora, se o demonstrar a prova oral produzida na instrução da causa." (TACrimSP - Ap. nº 913.181/4 - Birigui - 16ª Câm. - Rel. Juiz Eduardo Pereira - J. 23.02.95 - v.u.).

"Em sede de roubo, o desaparecimento do revólver não arreda a qualificadora do emprego de arma, se não desponta dúvida razoável de que um dos co-agentes o empregou" (TACRIM-SP-AC-Rel. Sérgio Pitombo - RJD 19/159).

Ainda no mesmo sentido:

"A segura imputação de vítima de roubo, cuja idoneidade não foi abalada, presta-se também a comprovar a circunstância do inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal, sem embargo de falta de apreensão de arma" (JTJ 179/276).

"Pouco importa à caracterização do roubo qualificado pelo emprego de arma não ter sido o revólver apreendido e não ter ficado provado o seu poder vulnerante" (RT 741/610-1).

Já decidi nesta Corte:

"ROUBO QUALIFICADO - Emprego de arma de fogo - Ausência de apreensão do artefato utilizado pelo agente - Irrelevância - Qualificadora evidenciada pela comprovação da utilização de arma para a perpetração do delito, em face da prova oral colhida e não impugnada (TJSP)" (RT 878/600).

"ROUBO QUALIFICADO - Emprego de arma - Não apreensão do artefato utilizado pelo agente - Irrelevância - Prova suprida pelo depoimento da vítima - Qualificadora que leva em conta a intimidação sofrida pela vítima e não o poderio do armamento utilizado (TJSP)" (RT 872/636)

"ROUBO QUALIFICADO. Concurso de agentes. Emprego de arma. Sentença condenatória. Insurgência. Afastamento da qualificadora do emprego de arma. Inadmissibilidade. Hipótese em que a não apreensão da arma empregada pelo agente na prática do roubo, não impede o reconhecimento da qualificadora, máxime se confirmada pela vítima e testemunha presencial. Recurso não provido" (Apelação Criminal n. 993.08.019984-1 São Paulo 5ª Câmara de Direito Criminal Relator: Marcos Zanuzzi 26.06.08 V.U. Voto nº 16.272)

De outra banda, o delito tipificado no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90 não restou bem demonstrado pela prova amealhada aos autos.

Em que pese a apresentação espontânea do adolescente J.D.A.S. em solo policial e sua narrativa de que seria ele o verdadeiro autor do crime, que teria praticado com outros dois comparsas cujos nomes não soube declinar, não há nos autos provas seguras a demonstrar a participação do adolescente no delito de roubo.

Veja-se que os policiais abordaram somente o réu e os indivíduos identificados como Marcos Antonio e Lucas. Nada relataram quanto à apreensão do menor J.D.A.S.

Ainda, colocado o menor J.D.A.S. ao lado do réu e dos outros dois indivíduos abordados pelos policiais (fls. 14), a vítima reconheceu somente o acusado como o autor do crime.

Não havendo prova suficiente, portanto, sobre o delito tipificado no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, deve ser o acusado absolvido desta imputação.

Assim, diante da prova produzida, conclui-se com tranquilidade a subsunção dos fatos narrados ao artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, sendo parcialmente procedente a ação penal.

Firmadas autoria e materialidade do delito, passo à dosagem da pena, atentando-me para o critério previsto no artigo 68 do Código Penal.

Atendendo às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, ao se analisar a culpabilidade (conjunto de todos os demais fatores, consubstanciando-se em verdadeiro critério genérico para limitar e fundamentar a pena - cf. NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da Pena, 3ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2009, pp. 170-174), verifica-se que o réu agiu com intensa agressividade, pois, após abordar a vítima mediante emprego de arma de fogo, sem que a vítima nada tenha feito, golpeou-a com a coronha da arma e, mesmo estando a vítima já rendida e deitada no chão, novamente a agrediu, demonstrando pouco caso com a vida e a saúde da vítima, o que denota ser ele detentor de personalidade transviada. Por essa razão, a pena-base deve ser aumentada em 1/6, ficando fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Considerando a situação econômica do réu, estabeleço o valor de cada dia-multa no mínimo legal, devendo ser corrigido desde a data dos fatos.

Na segunda fase da aplicação da pena, verifico que o delito foi cometido em ocasião de calamidade pública, agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência. De qualquer forma essa circunstância não pode ser ignorada, pois o isolamento social e a quarentena, em razão da pandemia, facilitam a prática do crime. Impõe-se, portanto, o aumento de pena pelo reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Contudo, reconhecida também a atenuante da menoridade relativa, ficam estas circunstâncias compensadas.

Na última fase do cálculo da pena, verifico que o roubo foi praticado com a majorante do concurso de duas ou mais pessoas, devendo ser a pena acrescida de 1/3. Dessa forma, efetuando-se o acréscimo mencionado, fica a pena fixada em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

Ainda, o crime foi praticado com a majorante descrita no §2º-A, inciso I, do artigo 157, em razão de ter sido a ameaça exercida com o emprego de arma de fogo. A pena deve ser acrescida de 2/3, ficando fixada em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, no valor já estabelecido.

Ressalte-se que inexistente ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade, ofensibilidade e razoabilidade decorrente do reconhecimento das duas majorantes do crime de roubo, uma vez que a conduta descrita no artigo 157, § 2º-A, do Código Penal é extremamente grave, o que levou o Legislador a decidir incrementar a pena diante da necessidade de enérgica reprovação e repressão.

Sendo assim, para garantia do princípio da separação dos poderes, não cabe ao Poder Judiciário interferir nas escolhas feitas pelo Poder Legislativo a respeito da apenação mais severa daqueles que praticam determinados crimes, em determinadas circunstâncias.

Nesse sentido, em caso análogo, já se decidiu:

"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 273, § 1º-B, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OPÇÃO POLÍTICO-LEGISLATIVA PARA APENAR DETERMINADOS DELITOS COM MAIOR SEVERIDADE. INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA INTERFERIR NAS ESCOLHAS FEITAS PELO PODER LEGISLATIVO. 1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 2. O Poder Judiciário não detém competência para interferir nas opções feitas pelo Poder Legislativo a respeito da apenação mais severa daqueles que praticam determinados crimes, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes. 3. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: "PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 273, § 1º e § 1º-B, INCISOS V e VI DO CÓDIGO PENAL. TRANSNACIONALIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. RECONHECIDO CONCURSO FORMAL." 4. Agravo regimental DESPROVIDO." (RE 829226 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 05-03-2015 PUBLIC 06-03-2015)

Outrossim, o parágrafo único do artigo 68 do Código Penal não traz a exigência de aplicação pelo Magistrado de uma única causa de aumento de pena quando houver concurso de majorantes. Trata-se de uma faculdade, que deve ser justificada, como o foi neste caso concreto.

Neste sentido:

"Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, "D" E "I". ROL TAXATIVO. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COMETIDO CONTRA MENOR (CP, ART. 214 C/C 224, "A") E DE PRODUÇÃO DE PORNOGRAFIA INFANTIL (ECA, ART. 241). ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DE "FOTOGRAFAR" MENORES EM CENAS DE SEXO EXPLÍCITO À ÉPOCA DOS ACONTECIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO GRAMATICAL E TELEOLÓGICA DO ART. 241 DO ECA, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 10.764/2003. IMPUGNAÇÃO DA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. DOSIMETRIA. REAPRECIÇÃO DOS ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA FIXAÇÃO DA PENA NA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO APRECIÇÃO DO TEMA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE AMPARO LÓGICO-TEXTUAL À APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DOS INCISOS I E II DO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. A conduta consubstanciada em "fotografar" cenas com pornografia envolvendo crianças e adolescentes amolda-se ao tipo legal previsto no art. 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), com redação dada pela Lei nº 10.764/2003, notadamente à expressão "produzir fotografia", cujo valor semântico denota o comportamento de "dar origem ao registro fotográfico de alguma cena". 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 241 do ECA, em razão de ter fotografado sua enteada de seis anos de idade em cenas de sexo explícito. Tipicidade da conduta devidamente caracterizada e apenada. 3. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011; HC 94073, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010. 4. Na espécie, o paciente teve sua pena majorada duas vezes ante a incidência concomitante dos incisos I e II do art. 226 do Código Penal, uma vez que, além de ser padastro da criança abusada sexualmente, consumou o crime mediante concurso de agentes. Boletim Criminal Comentado-março 2019 (semana 2) 8 Inexistência de arbitrariedade ou excesso que justifique a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal. 5. É que art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte

especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado. 6. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas "d" e "i", da Constituição Federal, sendo certo que a presente impetração não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 7. Habeas corpus extinto por inadequação da via processual." (HC 110960, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 23-09-2014 PUBLIC 24-09-2014)

Veja-se, ainda, especificamente acerca das causas de aumento de pena do crime de roubo após a vigência da Lei nº 13.654/18:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA.

CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, a aplicação das causas majorantes e minorantes se dá sem compensação, umas sobres as outras, não sendo admissível a pretendida tese de incidência de única majorante dentre as aplicáveis. 2. Tendo sido o crime de roubo praticado com o efetivo emprego de arma de fogo e ainda mediante concurso de cinco agentes, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento.

3. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC 512.001/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 29/08/2019)

"Apelação - Roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (fatos que ocorreram após o advento da Lei nº 13.654/18) - Materialidade e autoria demonstradas - Confissão dos réus, que foram presos em flagrante na posse dos bens subtraídos - Depoimentos das vítimas e dos policiais militares que atenderam a ocorrência suficientes para justificar o édito condenatório - Crime impossível não caracterizado - Pretensão à desclassificação para forma tentada do delito - Descabimento - Entendimento da Súmula 582, do C. STJ - Condenação mantida - Dosimetria - Penas-base fixadas no mínimo legal - Agravante da reincidência compensada com atenuante da confissão - Exasperação das penas em 1/3 pelo concurso de pessoas e elevada, novamente, em 2/3, pelo emprego de arma de fogo - Impossibilidade de reconhecimento de crime único - Concurso formal bem aplicado - Regime inicial fechado mantido - Recursos improvidos." (TJSP; Apelação Criminal 1502842-89.2018.8.26.0019; Relator (a): Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/10/2019; Data de Registro: 09/10/2019)

Torno essa pena definitiva na ausência de modificadoras.

Na forma do artigo 33 do Código Penal, em razão do montante de pena aplicado, observando-se, também, a gravidade inerente ao delito e as repercussões deste no meio social, tendo em vista que se trata de roubo praticado em concurso de agentes e com violência e com grave ameaça à pessoa exercida com emprego de arma de fogo e considerando-se, ainda, as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, tendo sido demonstrada, de forma concreta, sua especial periculosidade, fixo o regime inicial fechado como regime inicial do cumprimento de pena.

Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por outra espécie de pena diante da quantidade de pena imposta, bem como por ter sido o crime praticado

com violência e grave ameaça à pessoa, com emprego de arma de fogo, além das circunstâncias judiciais negativas já apontadas. Também pelos mesmos motivos, é incabível o sursis.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu GUILHERME CARDOSO PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, às penas de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, incidente a correção monetária, por infração ao disposto nos artigos 157, parágrafo 2º, inciso II e 2º-A, inciso I, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, e para ABSOLVÊ-LO da imputação que lhe foi feita de ter praticado o delito previsto no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, o que faço com supedâneo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por não estarem presentes os requisitos legais da prisão preventiva, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Ausente demonstração mínima suficiente de prejuízos sofridos pela vítima e não tendo havido pedido para tanto na denúncia, inviabilizando-se o contraditório, deixo de condenar o réu nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, sem prejuízo do direito de reparação do ofendido a ser perseguido na esfera cível.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Vicente, 25 de março de 2022.

ALEXANDRE TORRES DE AGUIAR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA